



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000580024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1535145-50.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SERGIO LUIZ DE CHIARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para: (i) absolver o réu da acusação referente a um dos crimes de ameaça, com base no artigo 386, III, do Código Penal; (ii) reduzir a pena para 4 meses e 12 dias de detenção. Mantida, no mais, a r. Sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e HERMANN HERSCHANDER.

São Paulo, 2 de agosto de 2018.

LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 1535145-50.2016.8.26.0562

Apelante: SERGIO LUIZ DE CHIARA

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Santos

Voto nº 8.951

Apelação. Crimes de lesão corporal e ameaça praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal de natureza leve e por dois delitos de ameaça, em continuidade delitiva. 2. O delito de ameaça, crime de perigo, é de natureza subsidiária, devendo ser absorvido pelo crime de lesão corporal, quando as ações ocorrem no mesmo contexto. Quadro de concurso aparente de normas. Absolvição em relação a uma das ameaças perpetradas contra a mulher. 3. Penas que comportam reparo. Mantido o sursis. 4. Recurso parcialmente provido.

1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 173/186), julgou procedente a ação para condenar **SERGIO LUIZ DE CHIARA** às penas de 4 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 147, “caput”, por diversas vezes, na forma do artigo 71, e artigo 129, par. 9º, todos do Código Penal, observado, entre os delitos de ameaça e lesão corporal, a regra do concurso material. Concedido o sursis pelo prazo de 2 anos, mediante as condições indicadas no artigo 78, par. 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Apelou a defesa, pleiteando a absolvição do réu, (i) por atipicidade, alegando crime impossível ou (ii) por falta de provas (fls. 188/200).

Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 224/226).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É o relatório.

2. Vinga em parte o reclamo. Na linha do que se segue.

3. Na esteira da denúncia, a r. sentença condenou o acusado (a) por um crime lesão corporal de natureza leve, bem como (b) por diversos crimes de ameaça (por palavras e por escrito), estes em continuidade delitiva.

4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu, embora não nos exatos termos postos na r. decisão de primeiro grau.

5. O quadro probatório – bem analisado pela r. sentença – desnuda a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Neste passo, o laudo pericial evidenciou ter a vítima sofrido lesões corporais de natureza leve (fls. 26/27).

Por sua vez, firme a prova oral no incriminar o acusado.

A vítima Bruna Castro Velista, ao ser ouvida em solo policial, confirmou as imputações. Narrou que foi abordada pelo acusado na rua, o qual aparentava estar transtornado e a ameaçava a todo tempo, dizendo que ia matá-la. Em dado momento passou a tentar sufocá-la e desferiu um tapa em sua boca, ferindo-a. Acrescentou que na data dos fatos o réu foi até seu local de trabalho e causou a sua demissão. Além disso, ele vinha ameaçando os familiares da declarante, dizendo que iria “queimar todo mundo” (fls. 5/6).

Ao ser ouvida novamente, quase um mês depois, relatou que o acusado não a deixava em paz, enviando-lhe mensagens ameaçadoras e injuriosas, com o seguinte teor “cuidado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

quando estiver chegando hoje em casa, muito cuidado”, além de chama-la de desgraçada, filha da puta, puta maldita, bem como outros impropérios. A declarante já gozava de medidas protetivas em desfavor do acusado e, na ocasião, representou criminalmente pelo crime de ameaça (fl. 24).

Certo que em juízo declinou versão diferente, buscando escusar o acusado. Informou que reataram o relacionamento, sendo que o réu é pai de sua filha pequena. Na data dos fatos, o réu veio conversar com a declarante para retomarem o relacionamento. A depoente ficou nervosa e começaram a discutir. “Foi para cima dele”, ao que o acusado, para se defender, tentou empurrá-la pelo pescoço. Estava usando capacete. A mão do réu esbarrou na boca da depoente e a machucou (em momento posterior da oitiva a ofendida diz que ele deu um tapa em sua boca). Pediu a medida protetiva porque não queria mais que o réu a incomodasse. Quanto às mensagens enviadas pelo réu para seu celular, o acusado as enviou porque ele havia enviado mensagens dizendo que a filha do casal estava com febre. Ligou para ele e constatou que era mentira, ao que discutiram. Por esta razão, ele ficou irritado e enviou as mensagens. As referências a uma outra pessoa se referem a um namorado que a declarante tinha na época.

Com efeito, mesmo a versão judicial, claramente tendente a amenizar a dinâmica dos fatos, não afasta peremptoriamente as condutas do réu consistentes em (i) desferir um tapa na boca da vítima e (ii) proferir ameaças. Ademais, considerando que o relacionamento foi reatado que o acusado é pai da filha da ofendida, compreensível a mudança na sua versão, devendo prevalecer, todavia, o relato ofertado na delegacia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a palavra do ofendido assume grande relevância probatória ([STJ, AgRg no AREsp nº 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC nº 179.364, rel. Min. Marco Antonio Bellizze](#)).

Seguindo a mesma trilha, a testemunha Ariane Castro Velista, irmã da ofendida, narrou que estava em casa dormindo quando foi acordada pela ofendida, que chorava e estava muito nervosa. Ela disse que havia discutido com o acusado e que ele havia dado um tapa em sua boca. Como ela usava aparelho, sua boca ficou com um pequeno corte. O relacionamento da casal era bastante conturbado, com muitas discussões (fl. 172 e mídia digital).

Além disso, foram juntadas as autos cópias das mensagens do réu ameaçando a vítima (fls. 16/23).

Trata-se, com efeito, de um manancial probatório robusto.

Certo que o réu repeliu as acusações. Afirmou que a vítima era agressiva e tomava remédios controlados. Quando se separaram, a ofendida o provocava frequentemente, sendo que as brigas começaram porque ele estava endividado. Na data dos fatos passou pela casa da ofendida e decidiu conversar com ela. A vítima o humilhou dizendo obscenidades. Começaram a discutir, ao que a vítima tentou agredir o declarante, que a empurrou pelo pescoço. Quando tentou afastar as mãos da ofendida, acabou batendo a mão em sua boca. A vítima não ficava com a filha porque estava com o namorado novo, sendo que, aos finais de semana, ao invés de ficar com a filha, mandava a menina para a casa dos avós. No dia da suposta ameaça, a ofendida lhe entregou a criança com febre. Tentou falar com ela por telefone, ao que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ela respondeu que ele deveria “se virar”. Dicutiram e se xingaram durante a ligação. Em seguida, a ofendida desligou e bloqueou o seu número no aparelho celular dela. Em razão disso, começou a escrever as mensagens para ela (fl. 169 e mídia digital).

Mas a versão não vinga. Pouco verossímil mercê das regras de experiência comum, acha-se escoteira nos autos.

E não impressionam, enquanto dados a escusar os réus, os depoimentos das testemunhas Maria Josefina Godinho Rezende, Sergio Luiz Ferreira Lima e Bruno de Oliveira Gomes, que nada sabiam sobre os fatos, apenas atestaram o bom caráter do réu (mídia digital).

Anote-se que as lesões constatas pelo laudo de exame de corpo de delito são compatíveis com a versão extrajudicial ofertada pela vítima (“edema de lábio superior com escoriações de mucosa” – fl. 27).

Nesta ordem de ideias, verte dos autos que o acusado agrediu a ofendida, que sofreu lesão corporal de natureza leve e (b) prometeu causar-lhe mal injusto e grave, tanto verbalmente quanto por mensagens de celular.

Registre-se que as infrações penais qualificam-se como delitos com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5º, II, da Lei nº 11.340/06).

6. O delito de ameaça, crime de perigo, é de natureza subsidiária, devendo ser absorvido pelo crime de lesão corporal, quando as ações ocorrem no mesmo contexto (**JULIO FABBRINI MIRABETE**, Código Penal Interpretado, Atlas, 5ª edição, pág. 1.170). Cuida-se de um quadro de concurso aparente de normas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Neste passo, a ameaça praticada contra a vítima no dia 25 de junho de 2016 fica absorvida pela lesão corporal.

Remanescem, todavia, as ameaças praticadas por mensagem de celular.

7. A sanção comporta reparo.

Em primeiro lugar, decota-se a pena imposta para o crime de ameaça em relação ao qual se decidiu, nesta oportunidade, pela absolvição.

7.1. Do crime de lesão corporal.

A pena de partida foi fixada no mínimo legal, em 3 meses de detenção, patamar em que se tornou definitiva, à míngua de causas modificadoras.

7.2. Dos crimes de ameaça.

A pena-base de cada um dos delitos foi fixada no mínimo legal, em 1 mês de detenção.

Na segunda fase, as penas foram aumentadas em 1/6 por força da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, chegando a 1 mês e 5 dias de detenção.

Diante da continuidade delitiva, considerando-se apenas as ameaças proferidas por mensagem de celular, toma-se a pena de um dos delitos aumentada em 1/5, dado que foram três as mensagens enviadas contendo ameaças (tal como descritas na denúncia). A sanção chega, assim, a 1 mês e 12 dias de detenção.

Com efeito, assentou-se a jurisprudência no sentido de que a majoração da pena em razão do crime continuado deve ser pautada pelo número de delitos, mais especificamente: 2 infrações, aumento de 1/6; 3 delitos, elevação de um 1/5; 4 crimes, majoração de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

um 1/4; 5 infrações, elevação de um 1/3; 6 delitos, aumento de 1/2; e 7 ou mais delitos, elevação de 2/3 (**STJ, AgRg no REsp nº 1.169.484, rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 147.987, rel. Min. Sebastião Reis Júnior**).

7.3. Por fim, somadas as penas, mercê do concurso material, alcança-se uma sanção final de 4 meses e 12 dias de detenção.

Não se altera o regime inicial aberto (artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, eis que os crimes foram praticados com emprego de violência e grave ameaça (artigo 44, I, do Código Penal).

Registre-se que se firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no caso de crime ou contravenção, cometidos com violência ou grave ameaça, notadamente quando se configure uma situação prevista na Lei nº 11.340/06, afigura-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (**STJ, Súmula nº 588; AgRg no REsp nº 1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC nº 190.411, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp nº 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio Bellizze; AgRg no REsp nº 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranhão; AgRg no Agravo em REsp nº 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz**).

Também o **Supremo Tribunal Federal** já recusou a aplicação do artigo 44, do Código Penal nesta situação (**HC nº 129.446, rel. Min. Teori Zavascki; HC nº 114.703, rel. Min. Gilmar Mendes; HC nº 131.219, rel. Min. Rosa Weber**).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Fica mantido o sursis..

8. Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao apelo para: (i) absolver o réu da acusação referente a um dos crimes de ameaça, com base no artigo 386, III, do Código Penal; (ii) reduzir a pena para 4 meses e 12 dias de detenção. Mantida, no mais, a r. Sentença.

LAERTE MARRONE
Relator